

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Sumilla: *"Se evidencia que al designarse el comité de selección en contravención al artículo 44 del Reglamento, que contiene las reglas previstas para la conformación del comité de selección, nos encontramos ante un órgano que no ha sido nominada regularmente, por lo que los actos que realizó (elaboración de bases y convocatoria) estaban afectadas por una causal de nulidad, esto es, por falta de competencia".*

Lima, 28 de marzo de 2023.

VISTO en sesión del 28 de marzo de 2023, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el **Expediente N° 2073-2023.TCE**, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Multimedical Supplies S.A.C., en el marco de la Licitación Pública N.º 003-2022-ESSALUD/CEABE – Primera Convocatoria (Ítem N° 33); y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 28 de enero de 2022, el Seguro Social de Salud (EsSalud), en adelante **la Entidad**, convocó la Licitación Pública N.º 003-2022-ESSALUD/CEABE – Primera Convocatoria, efectuada para la "Contratación de suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud de EsSalud, por un periodo de doce (12) meses – Material médico – 34 ítems", según relación de ítems, con un valor estimado total de S/ 114'890 177.98 (ciento catorce millones ochocientos noventa mil ciento setenta y siete con 98/100 soles), en adelante **el procedimiento de selección**.

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, en adelante **la Ley**, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF y modificatorias, en lo sucesivo **el Reglamento**.

El Ítem N° 33, materia de impugnación, tiene como objeto la contratación del respirador de pieza facial filtrante, por el valor estimado de S/ 13'304,305.91 (trece millones trescientos cuatro mil trescientos cinco con 91/100 soles).

Según el cronograma del procedimiento de selección, el 9 de setiembre de 2022, se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 30 de noviembre del mismo año, se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro del

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Ítem N° 33 del procedimiento de selección al postor Multimedical Supplies S.A.C., por el importe de S/ 5'843,682.34 (cinco millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y dos con 34/100 soles), obteniéndose los siguientes resultados¹:

POSTOR	ETAPAS			
	Admisión	Evaluación		Calificación y resultado
		Precio	Puntaje total obtenido	
Multimedical Supplies S.A.C.	Admitido	5'843,682.34	100.00 (1er. Lugar)	Calificado (Admitido)
Newid Corp S.A.C.	No admitido	-	-	No admitido
Consorcio de Lima N 95	No admitido	-	-	No admitido
Geomedic Peru E.I.R.L.	No admitido	-	-	No admitido
Cymed Medical S.A.C.	No admitido	-	-	No admitido
Consorcio Gaesa Medic E.I.R.L. – Gaesa Trading S.A.C.	No admitido	-	-	No admitido

El 9 de febrero de 2023, se notificó a través del SEACE la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 de la misma fecha, por medio de la cual la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección (referido a todos los ítems), retro trayéndolo a la etapa de convocatoria. Como sustento de dicha decisión, se señaló la falta de competencia del comité de selección, ya que, al momento de aprobarse las bases y de realizarse la convocatoria del procedimiento de selección, los miembros titulares y suplentes de dicho órgano colegiado no tenían vínculo contractual con la Entidad, al haberse emitido las órdenes de servicio con fecha posterior.

- Mediante Escrito N.º 1, presentado el 21 de febrero de 2023 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo **el Tribunal**, subsanado el 23 del mismo mes y año, a través del Escrito N.º 2, el proveedor Multimedical Supplies S.A.C., en adelante **el Impugnante**, interpuso recurso de

¹ Información extraída del “Formato N° 11: Acta de apertura de ofertas a través del SEACE, evaluación de las ofertas y calificación” de fecha 6 de octubre de 2022, sus anexos y el “Acta de otorgamiento de buena pro” de fecha 29 de noviembre de 2022.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

apelación contra la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 del 9 de febrero de 2023, solicitando, como pretensiones, que se deje sin efecto la declaratoria de nulidad del Ítem N.º 33 del procedimiento de selección y se declare firme el otorgamiento de la buena pro a su favor. Para sustentar su recurso, presenta los siguientes fundamentos:

Sobre la decisión de fondo:

- Señala que el comité sí es competente para aprobar las bases del procedimiento y realizar la convocatoria del mismo, en consecuencia, sus actos son eficaces y válidos. Para sustentar ello, se pronuncia sobre cada argumento del análisis contenido en la resolución impugnada.

Sobre la fecha de inicio del vínculo contractual de los miembros del comité de selección:

- Indica que la Entidad, declaró la nulidad del procedimiento de selección, sustentando, la supuesta falta de competencia de los miembros titulares del comité de selección, quienes estuvieron a cargo de aprobar las bases administrativas y de convocar el procedimiento de selección.

Recalca que la Entidad sostiene que, a la fecha de la designación del comité (26 de enero de 2022) y a la suscripción del “Acta de instalación y elaboración de bases” (28 de enero de 2022), los señores Heber Yony Mayhua García y Betty Huánuco Suárez no tenían una relación contractual con la Entidad, en tanto que la notificación de sus respectivas órdenes de servicio se dio días después, no teniendo en tales fechas vínculo contractual con la Entidad.

- Sobre el particular, señala que el argumentar de la Entidad, representaría que el comité de selección era incompetente o parcialmente incompetente, puesto que, dos de los tres miembros titulares, no tenían vínculo contractual con la Entidad del 26 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022, según lo demostrarían las órdenes de compra mediante las cuales la Entidad contrató los servicios de dichas personas.

Sobre la no consignación de su función de formar comités en los términos de referencia de las órdenes de servicio:

- Así también, expresa que la Entidad ha señalado que, en los términos de referencia de las órdenes de compra de algunos miembros del comité de

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

selección no se estableció expresamente la función referida a formar parte de comités de selección.

Sobre los requisitos de validez del acto administrativo y causales que sustentan la nulidad:

- Señala que, conforme al artículo 44 de la Ley, la Entidad puede declarar la nulidad del procedimiento de selección por alguna de las siguientes razones:
 - Cuando el acto ha sido dictado por órgano incompetente.
 - Cuando el acto contravenga las normas legales.
 - Cuando el acto contenga un imposible jurídico.
 - Cuando el acto prescinda de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la norma aplicable.
- Indica que, conforme lo manifestado en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 143-PE-ESSALUD-2023, la causa por la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, es que el comité de selección no tenía competencia.
- Manifiesta que, en atención al artículo 43 del Reglamento, el comité de selección es competente para preparar los documentos del procedimiento de selección y los actos necesarios; es decir, dentro de sus competencias está precisamente el aprobar el elaborar las bases del procedimiento de selección y convocar el mismo.

Sobre el cumplimiento de los requisitos de validez previstos en el artículo 44 del Reglamento:

- Alude que el artículo 44 del Reglamento establece que el comité de selección deberá estar integrado por tres miembros, de los cuales uno pertenezca al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y, por lo menos, uno tenga conocimiento técnico objeto de la contratación.

Asimismo, expresa que, para la conformación del comité de selección permanente, solo será exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones.

Añade que, cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades, a fin de que integren el comité de selección.

Además, el referido artículo contempla que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente, atendiendo a las reglas de la conformación señaladas precedentemente para cada miembro titular y su suplente, siendo la designación notificada por la Entidad a cada uno de sus miembros.

- Al respecto, indica que, la norma ha establecido sobre la designación y competencia del comité de selección, que la misma debe provenir de una decisión del titular de la entidad, o de quien hubiese designado estas funciones; además, que los miembros del comité de selección permanezcan en sus cargos hasta que sean removidos, por alguna de las causales también previstas en la norma.
- Asimismo, menciona que la normativa de contrataciones no ha detallado que, como un requisito determinante para la competencia del comité de selección, los integrantes de dicho órgano necesariamente deban poseer algún tipo de relación contractual con la Entidad; y, además, la naturaleza de tal vínculo contractual; es decir, no se ha precisado si los miembros del comité de selección deben de ser trabajadores de la entidad (en el sentido estricto del término), si deben poseer un vínculo contractual a través de la figura del CAS, o incluso si puede ser a través de una prestación de servicios (locación de servicios).
- Reitera que, para la competencia del comité de selección, la normativa de contrataciones solo establece que la misma debe responder a una designación proveniente del órgano competente.
- Además, menciona que, la designación fue efectuada por un órgano competente (Gerencia Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos), y como correlato a esta válida designación, los miembros del comité de selección presentaron sus declaraciones juradas, mediante las cuales manifiestan no poseer conflictos de intereses para ejercer tal encargo.
- Asimismo, señala que, los miembros del comité de selección permanecieron en sus funciones, hasta que el comité fue reconstituido posteriormente; es decir, ejercieron la competencia asignada, hasta que fue la propia entidad la

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

que posteriormente, y conforme a sus facultades cambió los miembros del comité.

- Según el principio de legalidad la entidad no puede exigir elementos que no hayan sido determinados en las normas pertinentes. Al respecto, la entidad alude a que la incompetencia del comité de selección vendría dada porque dos de los miembros titulares no tenían una relación contractual con la entidad (una relación contractual civil, de locación de servicios), pero no provee el respaldo legal para afirmar que la supuesta relación contractual sería un requisito de validez para la actuación del comité de selección, y mucho menos detalla la naturaleza que debería poseer la misma.
- La competencia del comité de selección viene dada por su designación por órgano competente, y la normativa no exige relación contractual alguna entre entidad y los miembros del comité de selección.
- Si se determinase que debería existir algún tipo de relación contractual entre la Entidad y miembros del comité de selección, se debe aplicar el principio de conservación del acto administrativo; pues la formalización de la relación contractual no es esencial, que resulta meridianamente claro que el contenido del acto administrativo hubiese sido el mismo; además la voluntad de la entidad era designar estas personas como miembros del comité, como lo ha efectuado en varios otros procedimientos de selección; entonces, la existencia del supuesto vicio no fue relevante, y no hubiese cambiado el destino del procedimiento.
- En relación al argumento de la entidad de que dentro de las órdenes de compra, mediante las cuales se contrató a algunos miembros del comité de selección, no se ha dispuesto de manera expresa dentro de las obligaciones de los contratados, el ser parte de comités de selección, señala que es poco serio y absurdo, pues dichos miembros presentaron sus correspondientes declaraciones juradas de intereses, y, si ello fuera así, no las habrían presentado y rechazado la designación, por lo que dichas personas estaban conformes con el encargo y las responsabilidades derivadas; en todo caso, aun cuando las funciones cuestionadas no estuvieran incluidas en los términos de la contratación cuando la entidad designa a la persona y la misma acepta el encargo, se habría ampliado los términos de esta relación contractual.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Sobre infracciones al principio de predictibilidad y vulneración a la seguridad jurídica

- Se ha vulnerado los principios de predictibilidad y seguridad jurídica, pues se está declarando la nulidad del procedimiento por un supuesto vicio en la convocatoria (inicios del año 2022), ya en la etapa del perfeccionamiento del contrato (cerca de un año después), situación que resulta irrazonable e inesperada para los proveedores, que han invertido tiempo y dinero en el procedimiento de selección y han llegado a coordinaciones y acuerdo con los fabricantes mundiales para cumplir sus obligaciones. Avalar el actuar de la entidad significaría afectar la confianza de los proveedores, quienes tendrían que realizar auditorías de los procedimientos de selección para estar seguros de su resultado, con los consiguientes costos que ello genera.

Sobre el comportamiento de la entidad contrario a la buena fe y a la doctrina de los actos propios

- La entidad se ha comportado de manera contraria a la buena fe y a la doctrina de los actos propios, pues fue la propia entidad quien designó a los miembros del comité de selección, aprobó las bases y convocó el procedimiento de selección, por lo que no debería valerse de sus propios vicios para conseguir una nulidad sin sustento.

Respecto de miembros del comité de selección realizaban sus funciones dentro de la Entidad

- Los miembros del comité de selección cuestionados realizaban funciones dentro de la entidad, así habrían remitido correos electrónicos a otras unidades de la entidad.

Sobre irregularidades y falta de objetividad al declarar la nulidad

- Advierte otras irregularidades y falta de objetividad al momento de declarar la nulidad, tales como que existirían dos versiones del Informe Legal N° 400-OAL-CEABE-ESSALUD-2022, de fecha 20 de diciembre de 2022, y que la decisión se adopte luego de un año desde la convocatoria y en la etapa del perfeccionamiento del contrato.
3. Con decreto del 24 de febrero de 2023, debidamente notificado en el SEACE el 27 del mismo mes y año, la Secretaría del Tribunal solicitó a la Entidad que emita su pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento del

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

procedimiento de selección, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del covid-19. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres (3) días hábiles.

Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE, y remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en efectivo en cuenta corriente, expedido por el Banco de la Nación, para su verificación.

4. El 2 de marzo de 2023, la Entidad registró en el SEACE el Informe legal N.º 081-GCAJ-ESSALUD-2023 de la misma fecha, elaborado por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, en el que se pronunció sobre el recurso de apelación, de acuerdo a lo siguiente:

Respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento:

- Señala que los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 “Procedimiento de selección en trámite” del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, establecen disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225; asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2020/TCE establece reglas para la implementación de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF en los recursos de apelación en trámite.
- Que, al respecto mediante solicitud de aprobación del Expediente de contratación N° 03-2022-GABE-CEABE-ESSALUD del 25 de enero de 2022, se observa que la aprobación del expediente de contratación estuvo a cargo de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos.
- Asimismo, señala que, respecto a la adecuación de protocolos, se encuentran a la espera de la información, por parte del área técnica, la cual será alcanzada a la brevedad.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Sobre la decisión de fondo:

Sobre la fecha de inicio del vínculo contractual de los miembros del comité de selección:

- Manifiesta que, de acuerdo a la Opinión N.º 128-2019/DTN del 19 de julio de 2019, se desprende que los integrantes del comité de selección deben encontrarse vinculados a la Entidad, ya sea al tenerlos como parte de su personal institucional, o como expertos independientes para cuyo fin deben tener un vínculo contractual (donde se señale de manera expresa que dentro de las actividades que realizará se encuentra la de integrar comités de selección), o a través de un acuerdo institucional, en cuyo caso la persona provendrá de otra Entidad.
- Recalca que la referida opinión menciona la necesidad de que, en caso de que se trate de expertos independientes del sector privado, las actividades que desarrollen deban encontrarse previstas en sus respectivos términos de referencia y que ello se vea reflejado en el respectivo contrato, incluyendo la actividad de integrar comités de selección.

Por tal motivo, considera que en caso esta actividad no se encuentre prevista de manera expresa, no se les podría atribuir la condición de expertos independientes y en consecuencia, no podrían integrar los comités, tal como se sustentó en la resolución impugnada.

Sobre la conservación del acto:

- Considera que no se puede conservar el vicio advertido, pues resulta trascendente.
5. Con decreto del 6 de marzo de 2023, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver; al respecto, el expediente se recibió en Sala el día 7 del mismo mes y año.
 6. A través del Escrito N° 3, presentado el 8 de marzo de 2023 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante, reiteró su solicitud de acumulación de las apelaciones que versen sobre la nulidad del procedimiento de selección Licitación Pública N° 03-2022-ESSALUD/CEABE-1, decretada a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 143-PE-ESSALUD-2023.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

7. Por decreto del 8 de marzo, se dejó a consideración de la Sala lo solicitado por el Impugnante.
8. Con otro decreto del 8 de marzo de 2023 se programó audiencia pública para el 15 del mismo mes y año.
9. El 15 de marzo de 2023, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la participación de los representantes del Impugnante y la Entidad.
10. A través del Escrito N° 4, presentado ante el Tribunal el 15 de marzo de 2023, el Impugnante solicitó se le proporcione copia de la grabación de la audiencia pública realizada el 15 de marzo de 2023.
11. Con decreto del 15 de marzo de 2023, se requirió a la Entidad remitir copia de los siguientes documentos:

“(…)

- (i) Resolución de Gerencia de la Central Abastecimiento de Bienes Estratégicos N.º 08-CEABE-ESSALUD-2022, mediante la cual se habría aprobado designar a los miembros del comité encargado de conducir la Licitación Pública N.º 03-2022-ESSALUD/CEABE, para la “Contratación de suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud de EsSalud, por un periodo de doce (12) meses – Material médico – 34 ítems.*
- (ii) Acta de instalación y elaboración de las bases administrativas de la Licitación Pública N.º 03-2022-ESSALUD/CEABE.*
- (iii) Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N.º 21-CEABE-ESSALUD-2022, mediante la cual se aprobó las bases administrativas de la Licitación Pública N.º 03-2022-ESSALUD/CEABE y se dispuso remitir el expediente de contratación al comité de selección.*

Señale la fecha y hora de aprobación de las bases administrativas de la referida licitación.

- (iv) Orden de Compra N.º 4503978363, mediante la cual se habría contratado los servicios del señor Heber Yony Mayhua García para la supervisión y control de las redes para la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico y Equipo Médico, así como el requerimiento que contenga los términos de*

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

referencia y/o especificaciones de la contratación.

Remitir también el documento en el que conste la notificación de la referida orden.

- (v) *Orden de Compra N.º 4503978769, mediante la cual se habría contratado los servicios de la señora Betty Huánuco Suárez para la supervisión y control de las redes para la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico y Equipo Médico, así como el requerimiento que contenga los términos de referencia y/o especificaciones de la contratación.*
 - (vi) *Informe N.º 1999-SGAYEC-GABE-CEABE-ESSALUD-2022, emitido por la Sub Gerencia de Adquisiciones y Ejecución Contractual de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos.*
 - (vii) *Informe N.º 400-OAL-CEABE-ESSALUD-2022, emitido por la Oficina de Asesoría Legal de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos.*
 - (viii) *Documento mediante el cual se trasladó a la empresa Multimедical Supplies S.A.C. los posibles vicios de nulidad detallados en los Informes N.º 1999-SGAYEC-GABE-CEABE-ESSALUD-2022 y N.º 400-OAL-CEABE-ESSALUD-2022.*
 - (ix) *Escrito(s) en los que la empresa Multimедical Supplies S.A.C. absuelve el traslado de los posibles vicios de nulidad.*
- (...)”.*

De igual forma, se le pidió remitir un informe técnico complementario, en el que detalle:

“(…)”

- (i) *El íter de las actuaciones referidas a la designación del comité de selección, desde su inicio hasta la participación en el otorgamiento de la buena pro; en ese sentido, se le solicita describir cuántas reconformaciones hubo, quiénes fueron los miembros en cada caso y en qué actuaciones participaron.*

En el caso de los señores Heber Yony Mayhua García y Betty Huánuco Suárez, precisar si luego de la culminación de las órdenes de servicio

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

mencionadas anteriormente, se les emitieron otras que los vinculara a la Entidad hasta la fecha en la que se dio la primera reconfiguración.

- (ii) *Señalar los motivos por los que se decidió reconfigurar en, al menos, dos oportunidades el comité de selección, teniendo en cuenta que el numeral 44.8 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, establece que los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada, mediante documento debidamente motivado.*

Acompañar los documentos sustentatorios que justificaron dicha remoción.

- (iii) *Elaborar una lista en la que detalle las órdenes de compra emitidas a los señores Heber Yony Mayhua García y Betty Huánuco Suárez, en el que señale: el objeto de su contratación, su plazo de ejecución, si es que los términos de referencia preveían su participación en comités de selección. Asimismo, remita una lista en la que detalle los procedimientos en los que dichas personas han participado como miembros de comités de selección, señalando la orden de servicio que respalda el ejercicio de dicha labor.*
- (iv) *Pronunciarse si es que considera que existe falta de competencia del comité de selección al momento del otorgamiento de la buena pro y deficiencias en el desarrollo del procedimiento de selección (relacionadas al requerimiento y las bases), debiendo detallar en qué consiste dicho defecto y sustentar la razón por la que considera que es un vicio.*
- (v) *Al CEABE, Indicar si la referencia en la resolución impugnada respecto a que se cautele que en la contratación de bienes de carácter permanente no se produzca fraccionamientos, se encuentra relacionado con que en el mismo año fiscal se hayan convocado diversos procedimientos para la contratación del suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud de EsSalud, por un periodo doce 12 meses.*

De no ser el caso, precisar por qué razón se hizo dicha precisión; señalar si esta tiene que ver con alguno de los vicios que comunicó al Impugnante, específicamente con el referido a los defectos en el requerimiento y las bases.

(...)”.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Para dicho efecto, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles.

12. Con decreto del 20 de marzo de 2023, se reiteró a la Entidad el pedido de información que se le efectuó, para lo cual se le otorgó el plazo de un (1) día hábil.
13. A través del Escrito N° 2, presentado ante el Tribunal el 20 de marzo de 2023, la Entidad remitió la información solicitada por decreto del 15 del mismo mes y año, adjuntando el Informe N° 548-SGAYEC-CEABE-ESSALUD-2023 del 20 de marzo de 2023, emitido por el Sub Gerente de Adquisición y Ejecución Contractual, por el cual se informó lo siguiente:

En cuanto a la conformación del comité de selección a lo largo del procedimiento de selección:

- Señala que al inicio se designó como miembros titulares del comité de selección a las siguientes personas:

Miembros titulares	Miembros suplentes
Presidente titular Jhony Crosby Poma Huayta	Presidente suplente Jorge Antonio Guerrero Quispe
Primer miembro titular Heber Yony Mayhua García	Primer miembro suplente Cinthya Huamán Tello
Segundo miembro titular Betty Huánuco Suárez	Segundo miembro suplente Luz Rossmery Melgarejo Acuña

Recalca que la convocatoria del procedimiento de selección se efectuó el 28 de enero de 2022, aun cuando las personas aludidas no contaban con vínculo contractual con la Entidad.

Detalla que los miembros titulares de dicho comité suscribieron el Acta de instalación y elaboración de bases e iniciaron las gestiones para la absolución de las ciento ochenta (180) consultas y observaciones a las bases.

Menciona que, debido a la gran cantidad de consultas y observaciones presentadas por los participantes, el procedimiento de selección se tuvo que postergar en varias ocasiones desde el 18 de febrero hasta el 8 de abril de 2022, fecha en la que el señor Heber Yony Mayhua García y la señora Betty Huánuco Suárez ya no laboraban en la Entidad.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Agrega que, en el caso de estos últimos, luego de haber culminado con las órdenes de servicios respectivas, no se emitieron órdenes adicionales que los vincularan con la Entidad hasta la fecha en que se dio la primera reconfiguración y, hasta ese entonces, el procedimiento de selección se encontraba en la etapa de absolución de consultas y observaciones; por lo que, concluye que al no haber vínculo con la Entidad, no se contaba con el quorum para integrar las bases del procedimiento.

- Menciona que el 10 de abril de 2022, se solicitó la reconfiguración del comité de selección y el 20 del mismo mes y año, se aprobó la primera reconfiguración a través de la Resolución N.º 156-CEABE-ESSALUD-2022, quedando este de la siguiente manera:

Miembros titulares	Miembros suplentes
Presidente titular Jhony Crosby Poma Huayta	Presidente suplente Alfredo Dancuart Alfaro
Primer miembro titular Gledy Katerin Martínez Palomino	Primer miembro suplente Cinthya Huamán Tello
Segundo miembro titular Pamela Victoria Barrios Ramos	Segundo miembro suplente Luz Rossmery Melgarejo Acuña

Señala que, una vez reconfigurado el comité de selección, se concluyó con la etapa de absolución de las consultas y observaciones y se culminó la etapa de integración de bases del procedimiento el 12 de mayo de 2022, fecha en la que el señor Jhony Crosby Poma Huayta y la señora Cynthia Huamán Tello no laboraban más en la Entidad.

- Luego de la integración de las bases se presentaron solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio, las cuales se elevaron al OSCE.

El 8 de agosto de 2022, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emitió el Pronunciamiento N.º 287-2022/OSCE-DGR y se publicó las bases integradas definitivas del procedimiento de selección. Según lo informado por la Entidad, el señor Alfredo Dancuart Alfaro ya no laboraba para su institución; por lo que, ante la ausencia del presidente titular, presidente suplente y primer miembro suplente, se solicitó por segunda vez la reconfiguración del comité de selección el 10 de agosto de 2022; es así que, mediante la Resolución N.º 417-CEACE-ESSALUD-2022, se reconfiguró el comité de selección de la siguiente manera:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Miembros titulares	Miembros suplentes
Presidente titular Luis Enrique Montesinos Mata	Presidente suplente Rels Hugo Juscamaita Palomino
Primer miembro titular Gledy Katerin Martínez	Primer miembro suplente Laddy Lily Cruz Santi
Segundo miembro titular Pamela Victoria Barrios Ramos	Segundo miembro suplente Luz Rossmery Melgarejo Acuña

- Los miembros titulares del comité de selección reconstituido por segunda vez continuaron con las etapas de presentación de ofertas, llevada a cabo el 9 de setiembre de 2022 e iniciaron con la evaluación de las ofertas durante los meses de setiembre, octubre y noviembre, debido a la gran cantidad de ofertas presentadas por los postores.
- Finalmente, el 29 de noviembre de 2022, se emitió el Acta de otorgamiento de la buena pro publicada en el SEACE, suscrita por los miembros titulares del comité de selección, Luis Enrique Montesinos Mata, Glendy Katerin Martínez Palomino y Pamela Victoria Barrios Ramos.

Al respecto, la Entidad ha señalado que los tres miembros titulares de dicho comité de selección, no tenían relación contractual con la Entidad porque cesaron sus servicios especializados el 22 de noviembre de 2022, conforme consta en sus respectivas actas de conformidad de servicios.

En cuanto a las órdenes emitidas a favor de los señores Heber Yony Mayhua García y Betty Huánuco Suárez:

- Precisa que, para la contratación del señor Heber Yony Mayhua García (primer miembro titular), se emitió la Orden de Compra N.º 4503978363, para prestar el servicio de un profesional (III) para la supervisión y control de las redes para la Sub-Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico, por el plazo de ejecución comprendido entre el 31 de enero al 5 de abril de 2022.

Al respecto, señala que, en los términos de referencia, no consigna como actividad participar o realizar funciones de integrar comités de selección; no obstante, el referido señor participó como miembro del comité de selección en la Licitación pública N.º 004-2022-ESSALUD/CEABE – Primera convocatoria (como segundo miembro) y la Licitación pública N.º 005-2022-ESSALUD/CEABE – Primera convocatoria (como primer miembro titular).

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

- En cuanto a la señora Betty Huánuco Suárez, indica que fue contratada mediante la Orden de Compra N.º 4503978769, para prestar el servicio de un profesional (IV) para la supervisión y control de las redes para la Sub-Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico, por el plazo de ejecución comprendido entre el 31 de enero al 9 de febrero de 2022.

Asimismo, detalla que en los términos de referencia no se consigna como actividad participar o realizar funciones de integrar comités de selección; no obstante, el referido señor participó como miembro del comité de selección en la Licitación pública N.º 004-2022-ESSALUD/CEABE – Primera convocatoria (como primer miembro suplente) y la Licitación pública N.º 005-2022-ESSALUD/CEABE – Primera convocatoria (como segundo miembro titular).

Pronunciamiento respecto a los dos vicios adicionales aludidos en las páginas 17 y 18 de la resolución impugnada:

- Alude que el vicio referido a defectos en el requerimiento y las bases, se encuentra en el literal B del numeral 5 de las Condiciones generales y requerimientos técnicos mínimos actualizadas para la contratación de suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud de EsSalud.

Al respecto, indica que, en el caso que los postores tengan la condición de micro y pequeña empresa, deben acreditar una experiencia que no supere el 25% del valor estimado, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante ocho años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, que se computarían desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago.

En esa línea, manifiesta que con la modificatoria aprobada en el año 2021, dicha disposición es aplicable a los ítems 1, 3, 5, 9, 18 y 26; no obstante, las bases no especificaron la distinción con respecto a los otros ítems, extendiendo dicho beneficio a los demás ítems.

- Asimismo, indica que los miembros titulares del comité de selección firmaron el acta de otorgamiento de la buena pro cuando ya no pertenecían a la institución, siendo sus ceses de servicios una causal para que no continúen realizando actos vinculados al procedimiento de selección, por no ser

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

competentes para ello, lo cual, según recalca, afecta la validez del procedimiento de selección.

En cuanto a los otros procedimientos de selección convocados cuyo objeto tiene la misma denominación:

- Manifiesta que la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), en el marco de sus atribuciones, tiene por finalidad la contratación de bienes estratégicos en salud y persigue el bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión transparente y eficiente.
- Precisa que, en ese contexto, realiza las gestiones para la contratación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para un periodo de doce meses, sin incurrir en fraccionamiento, toda vez que, para su convocatoria, los dispositivos médicos se agrupan de acuerdo a sus características técnicas, necesidades de las redes asistenciales de EsSalud, especialidades médicas, entre otras.

Asimismo, la Entidad remitió los documentos solicitados.

14. Por medio del Escrito N° 3, presentado el 21 de marzo de 2023 ante el Tribunal, la Entidad remitió una vez más el Informe N° 548-SGAYEC-CEABE-ESSALUD-2023 con sus anexos.
15. Mediante decreto del 21 de marzo del 2023, se declaró el expediente listo para resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento.
16. A través del Escrito N° 5, presentado ante el Tribunal el 23 de marzo de 2023, el Impugnante, presentó argumentos adicionales para mejor resolver, señalando lo siguiente:
 - Señala que, el señor Mayhua y la señora Huánuco, sí laboraban o prestaban servicios para la Entidad, con anterioridad al 31 de enero de 2022, es decir, existía un vínculo contractual entre estos dos miembros del comité de selección y la entidad, con independencia de que el mismo se haya formalizado mediante una orden de compra recién el 31 de enero, por lo que, no se da un supuesto de inexistencia de relación contractual, sino frente a un supuesto de una relación contractual efectiva con una formalización o regularización posterior.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

- Manifiesta que la Ley, no ha previsto como requisito de validez, que los miembros del comité de selección deban poseer vínculo contractual con la Entidad; asimismo, reitera que, para la competencia del comité de selección, la normativa de contrataciones solo establece que la misma debe responder a una designación proveniente del órgano competente, no estableciendo requisitos adicionales.
- Indica que, en el supuesto negado, en el cual se lograra demostrar que existe una obligación legal para que los miembros del comité de selección tengan una vinculación contractual específica con la entidad, corresponde aplicar el principio de conservación del acto administrativo.
- Señala que se habría vulnerado el principio del debido procedimiento, toda vez que, la Entidad declara la nulidad argumentando la falta de competencia del comité de selección; sin embargo, en todo su argumentar, se aprecia que son dos las razones por las cuales se determina la nulidad:
 - Falta de vinculación contractual entre la Entidad y los señores Mayhua y Huánuco.
 - En los términos de referencia de la contratación de múltiples miembros del comité de selección, no se menciona expresamente la conformación de comités de selección.

17. Por decreto del 23 de marzo de 2023, se dejó a consideración de la Sala, lo señalado por el Impugnante a través de su escrito presentado el mismo día.

FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por la empresa Multimedical Supplies S.A.C. contra la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 del 9 de febrero de 2023, mediante la cual el Seguro Social de Salud – EsSalud declaró la nulidad de la Licitación pública N.º 003-2022-ESSALUD/CEABE – Primera convocatoria (referido a todos los ítems), incluyendo el Ítem N.º 33, materia de impugnación.

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO:

1. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.

2. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

- a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo.

El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco.

Asimismo, con independencia del valor estimado o valor referencial del procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal.

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto contra la resolución que declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección, este Tribunal es competente para conocerlo.

- b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante,

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas.

En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la resolución que declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección; por consiguiente, el acto impugnado no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables.

c) Sea interpuesto fuera del plazo.

Los numerales 119.2 y 119.4 del artículo 119 del Reglamento establecen que la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles siguientes de tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

De igual modo, según el literal c) del artículo 122 del Reglamento, la omisión de los requisitos señalados en los literales b), d), e), f) y g) del artículo 121 – identificación del impugnante, el petitorio, las pruebas instrumentales pertinentes, la garantía por interposición del recurso y copia de la promesa de consorcio, cuando corresponda–, es subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación.

Teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación desde haber tomado conocimiento del acto impugnado; por lo que, teniendo en cuenta que la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 fue publicada en el SEACE el 9 de febrero de 2023, el plazo para impugnarla vencía 21 del mismo mes y año.

Precisamente, se aprecia que el 21 de febrero de 2023, el Impugnante presentó su primer escrito de impugnación y lo subsanó el 23 del mismo mes y año, es decir, dentro de los dos días hábiles posteriores; en ese sentido, se verifica que cumplió con los plazos descritos en los artículos 119 y 122 del Reglamento.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución Nº 01626-2023-TCE-S3

- d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

El recurso de apelación aparece suscrito por el señor Gustavo Risco Sotelo, apoderado del Impugnante.

- e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley.

Al respecto, no se advierte elementos a partir del cual se evidencie que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.

- f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se aprecian elementos que evidencien que el Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

- g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento.

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, a través del cual se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar debido a que la decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, incluida la buena pro otorgada a su favor, afecta de manera directa su derecho.

- h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, si bien el Impugnante fue adjudicado con la buena pro, el procedimiento de selección, incluyendo el otorgamiento de buena pro, se declaró nulo, siendo retrotraído a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

- i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante solicitó que se deje sin efecto la declaratoria de nulidad del Ítem N.º 33 del procedimiento de selección, aprobada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 del 9 de febrero de 2023, y se declare firme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia.

3. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del Reglamento, por lo que corresponde efectuar el análisis de los asuntos de fondo propuestos.

B. PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

- Se deje sin efecto la declaratoria de nulidad del Ítem N.º 33 del procedimiento de selección, aprobada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 del 9 de febrero de 2023.
- Se declare firme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso.

Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante el 27 de febrero de 2023 a través del SEACE, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían para absolverlo hasta el 2 de marzo del mismo año. Sin embargo, no se recibió ningún pronunciamiento.

5. En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste en:
 - Determinar si corresponde declarar nula la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 del 9 de febrero de 2023, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad del Ítem N.º 33 del procedimiento de selección, y, como consecuencia de ello, se ratifique la buena pro al Impugnante y se ordene que se proceda a la suscripción del contrato.

D. ANÁLISIS DEL ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO:

6. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

7. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley.
8. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación.

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar nula la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 del 9 de febrero de 2023, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad del ítem N.º 33 del procedimiento de selección, y, como consecuencia de ello, se ratifique la buena pro al Impugnante y se ordene que se proceda a la suscripción del contrato.

9. Según los antecedentes, en su recurso de apelación, el Impugnante ha señalado que el comité de selección que publicó la convocatoria del procedimiento de selección sí era competente para ello y que, por ende, no correspondía declarar la nulidad del referido procedimiento.

En tal sentido, para un mejor análisis resulta pertinente mostrar a continuación, los fundamentos de la Resolución que dieron lugar al acto ahora impugnado.

10. Sobre el particular, de la lectura de la resolución impugnada, se aprecian los siguientes fundamentos:

“Que, respecto a las personas designadas, se ha advertido que algunas no contaban con vínculo contractual con la Entidad y no fueron contratados para integrar Comités de Selección, conforme se detalla a continuación:

INTEGRANTES TITULARES				
Nombres	Número Orden	Emisión	Plazo de ejecución	Actividades
Jhony Crosby Poma Huayta	4503970843	21/01/2022	21/01/2022 al	Asistir y/o ser parte

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

			31/03/2022	integrante de los comités de evaluación en los procedimientos de selección
Heber Yony Mayhua García	4503978363	31/01/2022	31/01/2022 al 05/04/2022	No consigna
Betty Huánuco Suárez	4503978769	31/01/2022	31/01/2022 al 09/02/2022	No consigna

(...)

Que, se ha designado como integrantes titulares del Comité de Selección a dos (2) personas que no tenían vinculación con la Entidad y, adicionalmente, cuando se vincularon a la Entidad y, adicionalmente, cuando se vincularon a la Entidad no estaban en la facultad de integrar Comités de Selección;

(...)

Que, el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que: “44.1. El comité de selección está integrado por tres(3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación, asimismo, 44.4. Cuando la Entidad no cuenta con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección”, finalmente, establece que “44.5. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros”;

Que, la norma señala que quien designa al colegiado es el Titular de la Entidad, a menos que dicha facultad haya sido delegada en cuyo caso lo realiza el funcionario competente, designación que es efectuada por escrito y respetando las reglas de conformación que dicho artículo establece, entre las cuales se encuentra el número total de sus integrantes, la vinculación de estos con la Entidad, y el área al cual deben pertenecer o conocimiento que deben tener;

Que, en coherencia con lo mencionado, la Dirección Técnico Normativa del OSCE, a través de la Opinión N.º 128-2019/DTN ha señalado que, el comité de selección puede estar conformado por personas que no laboren en la Entidad, siempre y cuando se trate de expertos independientes, en caso tales expertos provengan del sector privado, las funciones que vayan a desempeñar – entre ellas, la de integrar el comité de selección – deberán encontrarse contempladas dentro de sus términos contractuales, de lo contrario no podrá atribuírseles dicha condición, y en consecuencia, no podrán participar como miembros del referido comité;

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Que, en ese sentido, al encontrarnos ante un Comité integrado por personas que no tenían la calificación (vínculo contractual ni funciones para integrar el colegiado) para ser parte de dicho Comité, advertimos que se trata de un órgano incompetente, situación que se deriva de que la designación efectuada vulnera el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que al momento de la emisión de la Resolución de conformación no se han seguido las reglas establecidas por el mismo artículo;

Que, ante dicho escenario, es importante (sic) considerar los actos que realiza el colegiado, es así que, en cuanto a las funciones que tienen a su cargo encontramos que el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento señala que el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación, es así que el Comité participa desde la preparación de los procedimientos de selección, que abarcan las actividades previas a la convocatoria del procedimiento de selección, como sería la revisión del expediente de contratación para la elaboración de las bases administrativas. Además de ello, luego de convocado le corresponde conducir dicho procedimiento, para lo cual, participa de las diferentes etapas, es decir, una vez que el expediente de contratación es entregado al Comité de Selección, este se encarga de dirigir todo el procedimiento de selección, incluyendo la elaboración de los documentos tales como las bases administrativas, hasta que dicho procedimiento culmine;

Que, el numeral 43.3 del referido artículo señala que los Comités de Selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación;

Que, para la elaboración de las Bases, de conformidad con el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se utilizan obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado, sin embargo, es pertinente recordar que los factores de evaluación no se encuentran determinados en el expediente de contratación, debido a que son definidos por el Comité de Selección;

Que, respecto al quórum y acuerdo que adopta el mencionado Comité, se tiene que en el numeral 46.2 del artículo 46 del Reglamento, se dispone que, para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de selección se sujeta a las siguientes reglas: a) El quórum para el funcionamiento del comité de selección se da con la presencia del número total de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo suplente, y b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de los integrantes;

Que, la norma exige que para la sesión de los Comités de Selección se cuente con el total de sus integrantes, tal es así que en caso de que se produzca la ausencia de alguno, el respectivo suplente procede a reemplazarlo, condición que debe darse para tener una sesión válida; asimismo, el Comité de Selección determina su actuación sobre la base de la información que obra en el expediente de contratación,

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

sin que pueda alterar su contenido;

Que, de otro lado, si bien la elaboración de las Bases se sujeta al contenido del expediente de contratación, la determinación de los factores de evaluación es competencia del colegiado, para cuyos acuerdos se deben tener en cuenta el quórum para sesionar y para adoptar acuerdos;

Que, en la línea de análisis, la vulneración normativa en la designación ha conllevado a que se haya designado a un colegiado que no tenía la competencia para preparar y desarrollar el procedimiento de selección, generando que las acciones posteriores se encuentren viciadas por haber sido dirigidas por un órgano incompetente, pues se debieron designar a personas diferentes para integrar el Comité, por tanto, el vicio se ha incurrido en la designación del Comité de Selección;

Que, respecto a la inobservancia legal expuesta, es pertinente traer a colación la regulación en torno a la nulidad en materia de contrataciones del Estado:

“Artículo 44.- Declaratoria de nulidad

44.1. El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescendan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

44.2. El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas – Perú Compras, en los procedimientos de implementación o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco.

(...)”.

Que, se determina que la vulneración a las normas legales constituye en un vicio de nulidad. En ese sentido, en el caso materia de análisis, la designación del Comité de Selección se hizo vulnerando el artículo 44 del Reglamento, lo que conlleva a que todas las actuaciones realizadas por dicho Comité adolecen del vicio de nulidad que también se encuentra previsto en la citada norma;

(...)

Que, considerando que se produjo una vulneración al marco normativo en la designación en el Comité de Selección, ya que se designó a un órgano incompetente al contravenir el artículo 44 del Reglamento, las demás actuaciones desarrolladas por dicho Colegiado se deberían tener por no efectuadas, dada la trascendencia del vicio incurrido;

Que, correspondería declarar la nulidad del procedimiento de selección, y que el mismo sea retrotraído a la etapa de convocatoria, previa designación de un Comité de Selección que tenga competencia.

Que, Alberto Retamozo Linares, indica que “(...) la convocatoria constituye un acto administrativo por canto es una declaración unilateral, dictada en ejercicio de la función administrativa productora de efectos jurídicos individuales y directos,

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

mediante el cual se exterioriza la voluntad de la entidad pública de contratar “sujetándose a las bases y cláusulas elaboradas para su preparación y ejecución”, comunicando, para tal efecto, su decisión a todas las personas naturales o jurídicas para que participen del procedimiento de selección presentando sus propuestas. A través de la convocatoria, la Administración pública comunica y explica a los interesados “lo que desea y aclara cuándo y dónde deberán ofrecer sus propuestas”;

Que, uno de los elementos de validez es la competencia, la cual significa que deben emitir sus decisiones cumpliendo con exigencias como quórum, aspecto que, al momento de la instalación, elaboración de documentos del procedimiento y convocatoria, no existía, pues los integrantes no tenían tal competencia debido a que en su designación se vulneró la normativa en Contrataciones del Estado, al considerar a personas que no tenían vínculo contractual con la Entidad y que, adicionalmente, no tenían dentro de sus funciones integrar comités de selección;

Que, en la designación del Comité de Selección de la Licitación Pública N.º 03-2022-ESSALUD/CEABE-1, efectuada mediante Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N.º 08-CEABE-ESSALUD-2022, de fecha 26 de enero de 2022, se ha incurrido en la vulneración del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta situación implica una vulneración normativa que conlleva a que nos encontremos ante un órgano incompetente para desarrollar las actuaciones del procedimiento de selección, situación que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, constituye en un supuesto para la declaratoria de nulidad, debiendo retrotraer el citado procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reconfiguración del Comité de Selección;

Que, el vicio resulta ser trascendente, toda vez que con la designación de otras personas con la competencia para integrar el Comité de Selección, si bien varias actuaciones que se realizaron conllevan a considerar únicamente la información que obra en el expediente de contratación aprobado, también se reconoce que en la formulación de las bases la determinación de los factores de evaluación depende de cada Comité, para cuya decisión se consideran las reglas sobre quórum para sesionar y adoptar acuerdos, en consecuencia, resulta inviable determinar si la designación un Comité con integrantes competentes hubiera determinado que las Bases del procedimiento de selección contengan las mismas reglas (los mismos factores de evaluación), por lo que no se puede aplicar el numeral 14.5.4 del artículo 14 de la LPAG que señala la viabilidad de conservar los actos cuando se concluya indubitadamente de cualquier otro modo que el acto hubiese tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio, aspecto que conlleva a que se haga inviable conservar los actos dictados por el Comité de Selección que no tenía la competencia;
(...)”.

11. Tal como se observa, la Entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección, bajo el sustento que el comité de selección que participó en la elaboración de las bases administrativas (que incluyen los factores de evaluación) y publicó la convocatoria del procedimiento de selección estaba integrado por dos personas que no tenían la calificación (no tenían vínculo contractual ni sus términos de

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

referencia detallaban como parte de sus funciones el conformar comités) para ser parte de dicho comité de selección.

En esa medida, determinó que se trataba de un órgano incompetente, habiéndose vulnerado el artículo 44 del Reglamento, debido a que al momento de la emisión de la resolución de conformación no se siguieron las reglas establecidas por el mismo artículo.

12. Frente a ello el Impugnante ha manifestado que considera que el comité de selección, sí es competente para aprobar las bases del procedimiento y realizar la convocatoria del mismo, en consecuencia, sus actos son eficaces y válidos, y menciona lo siguiente:

- Sobre la fecha de inicio del vínculo contractual de los miembros del comité de selección, señala que la normativa de contrataciones no ha detallado que, como un requisito determinante para la competencia del comité de selección, los integrantes de dicho órgano necesariamente deban poseer algún tipo de relación contractual con la Entidad ni tampoco la naturaleza de tal vínculo contractual. En ese sentido, sostiene que no se ha precisado si los miembros del comité de selección deben de ser trabajadores de la entidad (en el sentido estricto del término), si deben poseer un vínculo contractual a través de la figura del CAS, o incluso si puede ser a través de una prestación de servicios (locación de servicios).
- Sobre la no consignación de su función de formar comités en los términos de referencia de las órdenes de servicio, refiere que según el principio de legalidad la Entidad no puede exigir elementos que no hayan sido determinados en las normas pertinentes.

Enfatiza que el argumento de la Entidad, respecto a que no se ha dispuesto de manera expresa entre las obligaciones de los contratados, el ser parte de comités de selección, lo considera poco serio y absurdo, pues dichos miembros presentaron declaraciones juradas de intereses, por lo que dichas personas estaban conformes con el encargo y las responsabilidades derivadas; en todo caso, aun cuando las funciones cuestionadas no estuvieran incluidas en los términos de la contratación, sostiene que cuando la Entidad designa a la persona y esta acepta el encargo, se habría ampliado los términos de su relación contractual. Agrega que de determinarse algún tipo de relación contractual entre la Entidad y miembros del comité de selección, se debe aplicar el principio de conservación del acto administrativo.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

- Sobre el cumplimiento de los requisitos de validez previstos en el artículo 44 del Reglamento, refiere cómo debe ser integrado un comité de selección (tres miembros, uno debe pertenecer al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y, por lo menos, uno tenga conocimiento técnico objeto de la contratación) y que para la conformación del comité de selección permanente, solo será exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones.

Añade entre otros, que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, siendo la designación notificada por la Entidad a cada uno de sus miembros.

En esa línea, sostiene que para la competencia del comité de selección, la normativa de contrataciones solo establece que la misma debe responder a una designación proveniente del órgano competente (Gerencia Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos), y como correlato a esta válida designación, los miembros del comité de selección presentaron sus declaraciones juradas, mediante las cuales manifiestan no poseer conflictos de intereses para ejercer tal encargo.

- Considera que se ha vulnerado los principios de predictibilidad y seguridad jurídica, pues se está declarando la nulidad del procedimiento por un supuesto vicio en la convocatoria (inicios del año 2022), ya en la etapa del perfeccionamiento del contrato (cerca de un año después), situación que resulta irrazonable e inesperada para los proveedores, que han invertido tiempo y dinero en el procedimiento de selección y han llegado a coordinaciones y acuerdo con los fabricantes mundiales para cumplir sus obligaciones. Avalar el actuar de la Entidad significaría afectar la confianza de los proveedores, quienes tendrían que realizar auditorías de los procedimientos de selección para estar seguros de su resultado, con los consiguientes costos que ello genera.
- La Entidad se ha comportado de manera contraria a la buena fe y a la doctrina de los actos propios, pues fue quien designó a los miembros del comité de selección, aprobó las bases y convocó el procedimiento de selección, por lo que no debería valerse de sus propios vicios para conseguir una nulidad sin sustento. Sostiene que los miembros del comité de selección cuestionados realizaban funciones dentro de la Entidad, así habrían remitido correos electrónicos a otras unidades de la Entidad.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

- Considera que irregularidades y falta de objetividad al momento de declarar la nulidad, tales como que existirían dos versiones del Informe Legal N° 400-OAL-CEABE-ESSALUD -2022, de fecha 20 de diciembre de 2022, y que la decisión se adopte luego de un año desde la convocatoria y en la etapa del perfeccionamiento del contrato.

- 13.** A su turno, la Entidad registró el Informe legal N.º 081-GCAJ-ESSALUD-2023, elaborado por la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, en el que se remitió a la Opinión N.º 128-2019/DTN del 19 de julio de 2019, la cual, según advierte, los integrantes del comité de selección deben encontrarse vinculados a la Entidad, ya sea al tenerlos como parte de su personal institucional, o como expertos independientes para cuyo fin deben tener un vínculo contractual (donde se señale de manera expresa que dentro de las actividades que realizará se encuentra la de integrar comités de selección), o a través de un acuerdo institucional, en cuyo caso la persona provendrá de otra Entidad.

Recalca que la referida opinión menciona la necesidad de que en caso de que se trate de expertos independientes del sector privado, las actividades que desarrollen deban encontrarse previstas en sus respectivos términos de referencia y que ello se vea reflejado en el respectivo contrato, incluyendo la actividad de integrar comités de selección.

Por tal motivo, considera que en caso esta actividad no se encuentre prevista de manera expresa, no se les podría atribuir la condición de expertos independientes y en consecuencia, no podrían integrar los comités, tal como se sustentó en la resolución impugnada.

- 14.** Según se colige de los argumentos de las partes, ambos tienen opiniones distintas respecto a si el comité que participó en la elaboración de bases y convocatoria del procedimiento de selección se encontraba debidamente conformado; pues, para el Impugnante, no sería necesario que los miembros del comité de selección mantengan un vínculo contractual o laboral para que puedan conformar dicho colegiado, mientras que para la Entidad sí sería necesario que haya dicho vínculo, a fin de que se considere que la persona se encuentra hábil para conformar el comité de selección.

Por ello, a continuación se examinan las nociones generales a considerar sobre las materias relacionadas con la controversia.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Sobre el ámbito de las funciones del comité de selección y su conformación:

15. El artículo 8 de la Ley, que regula sobre los funcionarios, dependencias y órganos a cargo de las contrataciones, establece que la Entidad puede conformar comités de selección, a los cuales los define como órganos colegiados encargados de seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación, precisando que en el Reglamento establece su composición, funciones, responsabilidades, entre otros.

Por su parte, el Artículo 9 de la Ley, que regula las Responsabilidades esenciales de los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo.

Asimismo, establece que, de corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

En concordancia con las normas de la Ley antes citadas, en el artículo 43 del Reglamento establece que el órgano a cargo de los procedimientos de selección se encarga de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. Los procedimientos de selección pueden estar a cargo de un comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, siendo que para la licitación pública (como es el caso), el concurso público y la selección de consultores individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento.

En cuanto a sus funciones, los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación.

16. Ahora bien, en cuanto a su designación, el artículo 44 del Reglamento – norma que se ha vulnerado según la Entidad– establece lo siguiente:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

“Artículo 44. Designación, suplencia, remoción y renuncia de los integrantes del comité de selección

- 44.1. El comité de selección está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) pertenece al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad y por lo menos uno (1) tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación.*
- 44.2. Tratándose de los procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras, consultoría en general y consultoría de obras, de los tres (3) miembros que forman parte del comité de selección, por lo menos, dos (2) cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, salvo lo previsto en el artículo 217.*
- 44.3. Para la conformación del comité de selección permanente solo es exigible que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las contrataciones.*
- 44.4. Cuando la Entidad no cuente con especialistas con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección.*
- 44.5. El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta atribución, designa por escrito a los integrantes titulares y sus respectivos suplentes, indicando los nombres y apellidos completos, la designación del presidente y su suplente; atendiendo a las reglas de conformación señaladas en los numerales precedentes para cada miembro titular y su suplente. La designación es notificada por la Entidad a cada uno de los miembros.*
- 44.6. El órgano encargado de las contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de contratación aprobado, para que dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección y realice la convocatoria.*
- 44.7. Los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia de los titulares. En dicho caso, la Entidad evalúa el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la participación del suplente.*
- 44.8. Los integrantes del comité de selección solo pueden ser removidos por caso fortuito o fuerza mayor, por cese en el servicio, conflicto de intereses u otra situación justificada, mediante documento debidamente motivado. En el mismo documento puede designarse al nuevo integrante.*

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

44.9. Los integrantes del comité de selección no pueden renunciar al cargo encomendado, salvo conflicto de intereses. En este caso, la renuncia se presenta por escrito detallando las razones que sustentan el conflicto de intereses. Incurrir en responsabilidad el servidor que temeraria o maliciosamente alega un conflicto de intereses inexistente con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones.”

Nótese que el numeral 44.1 antes acotado exige que de los tres miembros que conforman el comité de selección, uno pertenezca al órgano encargado de las contrataciones de la entidad; es decir, este miembro, necesariamente debe pertenecer a la entidad.

Ahora bien, los miembros que son designados porque tienen conocimiento técnico en el objeto de la contratación, también deben pertenecer a la entidad, pues el numeral 44.4 del antes citado artículo establece que solo cuando la entidad no cuente con estos especialistas puede contratar expertos independientes o gestionar el apoyo de expertos de otras Entidades a fin de que integren el comité de selección.

Asimismo, el numeral 44.8 establece como causal de la remoción del cargo de miembro de comité de selección, el cese en el servicio, lo que implica que la persona designada como miembro del comité de selección debe mantener algún tipo de vínculo contractual o laboral con la Entidad o con otras Entidades.

En la misma línea, tal como ha indicado la Dirección Técnico Normativa en la Opinión N.º 128-2019/DTN, en principio, el comité de selección es conformado con el personal de la propia Entidad, a menos que esta no cuente con especialistas en el objeto de la contratación, situación en la cual se puede convocar expertos independientes para que integren dicho comité, pudiendo ser estos: (i) personas del sector privado, en cuyo caso deberá gestionarse su respectiva contratación, o (ii) expertos de otras Entidades, en cuyo caso deberá mediar entre ambas instituciones un acuerdo que así lo determine.

Cabe precisar que las labores que desempeñen los expertos independientes que provengan del sector privado –entre ellas, las de integrar el comité de selección– deben encontrarse previstas en sus términos de referencia y verse reflejadas en el respectivo contrato, de lo contrario no se les podrá atribuir dicha condición, y en consecuencia, no podrán integrar el referido comité.

De esta manera, el comité de selección puede estar conformado por personas que no laboren en la Entidad siempre y cuando se trate de expertos independientes;

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

en caso dichos expertos provengan del sector privado, las funciones que vayan a desempeñar deberán encontrarse contempladas dentro de sus términos contractuales.

En adición a lo señalado, resulta importante mencionar que la contratación de expertos independientes –tal como se infiere del artículo 44 del Reglamento– tiene un carácter netamente excepcional, por lo que solo debe utilizarse cuando se determine que la Entidad no cuenta con especialistas que posean conocimientos técnicos en el objeto de contratación.

Adicionalmente, en el artículo 217 del Reglamento, que regula la conformación del órgano a cargo del procedimiento de selección sujeto a las modalidades de concurso oferta y llave en mano, se establece que el comité de selección debe estar conformado por cinco (5) miembros, según las siguientes condiciones: a) Un (1) miembro del órgano encargado de las contrataciones. b) Un (1) miembro del área usuaria o la que haga sus veces. c) Tres (3) expertos independientes con conocimiento especializado en la elaboración de expedientes técnicos de la especialidad de la obra a contratar. Previo sustento, que conste en el expediente de contratación, los expertos designados pueden ser servidores de la Entidad.

Lo que ratifica la exigencia que para conformar debe tenerse un vínculo jurídico con la Entidad, ya sea laboral o contractual.

17. En el caso concreto, a partir de la información publicada en el SEACE y los documentos remitidos por la Entidad a través del Informe N.º 548-SGAYEC-CEABE-ESSALUD-2023, se verifican los siguientes hechos:

- El 24 de enero de 2022, se incluyó en el Plan Anual de Contrataciones el suministro de dispositivos médicos para los establecimientos de salud de EsSalud, por un periodo de doce (12) meses – Material médico – 34 ítems, aprobándose el día posterior el expediente de contratación.
- El 26 de enero de 2022, el gerente central de Abastecimiento de Bienes Estratégico, Marcos León Vásquez, suscribió la Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N.º 08-CEABE-ESSALUD-2022, mediante la cual **se designó a los miembros del comité de selección para el procedimiento de selección**, siendo estos los siguientes:

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Miembros titulares	Miembros suplentes
Presidente titular Jhony Crosby Poma Huayta En calidad de representante de la Sub-Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos – CEABE.	Presidente suplente Jorge Antonio Guerrero Quispe En calidad de representante de la Sub-Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos – CEABE.
Primer miembro titular Heber Yony Mayhua García En calidad de representante de la Sub-Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos - CEABE.	Primer miembro suplente Cinthya Huamán Tello En calidad de representante de la Sub-Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos - CEABE.
Segundo miembro titular Betty Huánuco Suárez En calidad de representante de la Sub-Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos - CEABE.	Segundo miembro suplente Luz Rossmery Melgarejo Acuña En calidad de representante de la Sub-Gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos - CEABE.

- El 28 de enero de 2022, el gerente central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de la Entidad suscribió la Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N.º 21-CEABE-ESSALUD-022, mediante la cual se aprobó las bases administrativas del procedimiento de selección y se remitió el expediente de contratación al comité de selección, para su posterior publicación.

En la misma fecha, dicho comité de selección suscribió el “Acta de instalación y elaboración de bases”, a través del cual dejó constancia que recibió el expediente de contratación y prosiguió con la elaboración de las bases administrativas.

- El 31 de enero de 2022, la Entidad emitió la Orden de compra N° 4503978363, a favor del señor Heber Yony Mayhua García, para la contratación del servicio de un profesional (III) para la supervisión y control de las redes para la Sub-gerencia de Determinación de Necesidades y

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos.

Asimismo, en la misma fecha, la Entidad emitió la Orden de compra N.º 4503978769, a favor de la señora Betty Huánuco Suárez, para la contratación del servicio de un profesional (V) para la supervisión y control de las redes para la Sub-gerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos.

- De acuerdo a lo que ha mencionado la Entidad en el Informe N.º 544-SGAYEC-CEABE-ESSALUD-2023, debido a la gran cantidad de consultas y observaciones presentadas por los participantes, el procedimiento de selección se tuvo que postergar en varias ocasiones desde el 18 de febrero hasta el 8 de abril de 2022, fecha en la que el señor Heber Yony Mayhua García y la señora Betty Huánuco Suárez ya no laboraban en la Entidad.

Asimismo, refirió que, en el caso de estos últimos, luego de haber culminado con las órdenes de servicios respectivas, no se emitieron órdenes adicionales que los vinculara con la Entidad hasta la fecha en que se dio la primera reconfirmación y, hasta ese entonces, el procedimiento de selección se encontraba en la etapa de absolución de consultas y observaciones.

- El 20 de abril de 2022, se emitió la Resolución N.º 156-CEABE-ESSALUD-2022, a través de la cual se aprobó la primera reconfirmación del comité de selección, quedando este de la siguiente manera:

Miembros titulares	Miembros suplentes
Presidente titular Jhony Crosby Poma Huayta	Presidente suplente Alfredo Dancuart Alfaro
Primer miembro titular Gledy Katerin Martínez Palomino	Primer miembro suplente Cinthya Huamán Tello
Segundo miembro titular Pamela Victoria Barrios ramos	Segundo miembro suplente Luz Rossmery Melgarejo Acuña

- Luego de la integración de las bases se presentaron solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio, las cuales se elevaron al OSCE.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

El 8 de agosto de 2022, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emitió el Pronunciamiento N.º 287-2022/OSCE-DGR y se publicó las bases integradas definitivas del procedimiento de selección. Según lo informado por la Entidad, el señor Alfredo Dancuart Alfaro ya no laboraba para su institución; por lo que, ante la ausencia del presidente titular, presidente suplente y primer miembro suplente, se solicitó por segunda vez la reconfirmación del comité de selección el 10 de agosto de 2022; es así que, mediante la Resolución N.º 417-CEACE-ESSALUD-2022, se reconfirmó el comité de selección de la siguiente manera:

Miembros titulares	Miembros suplentes
Presidente titular Luis Enrique Montesinos Mata	Presidente suplente Rels Hugo Juscamaita Palomino
Primer miembro titular Gledy Katerin Martínez	Primer miembro suplente Laddy Lily Cruz Santi
Segundo miembro titular Pamela Victoria Barrios Ramos	Segundo miembro suplente Luz Rossmery Melgarejo Acuña

- Los miembros titulares del comité de selección reconfirmado por segunda vez continuaron con las etapas de presentación de ofertas, llevada a cabo el 9 de setiembre de 2022 e iniciaron con la evaluación de las ofertas durante los meses de setiembre, octubre y noviembre, debido a la gran cantidad de ofertas presentadas por los postores.
- Finalmente, el 29 de noviembre de 2022, se emitió el Acta de otorgamiento de la buena pro publicada en el SEACE, suscrita por los miembros titulares del comité de selección, Luis Enrique Montesinos Mata, Glendy Katerin Martínez Palomino y Pamela Victoria Barrios Ramos.

Al respecto, la Entidad ha señalado que los tres miembros titulares de dicho comité de selección, no tenían relación contractual con la Entidad porque cesaron sus servicios especializados el 22 de noviembre de 2022, conforme consta en sus respectivas actas de conformidad de servicios.

18. Se evidencia que el comité de selección que aprobó las bases administrativas y publicó la convocatoria del procedimiento de selección, al 28 de enero de 2022, fecha en que se realizaron tales actos, los señores Heber Yony Mayhua García y Betty Huánuco Suárez no mantenían vínculo laboral o contractual con la Entidad y es recién el 31 del mismo mes y año que se emitieron las respectivas órdenes de servicio a su favor.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

19. En su recurso, el Impugnante también ha señalado que el señor Heber Yony Mayhua García y la señora Betty Huánuco Suárez realizaban funciones dentro de la Entidad, para lo cual mostró correos electrónicos que aparentemente remitieron a otras unidades de la Entidad; por dicha, considera que formaban parte de la Entidad. Asimismo, el Impugnante ha señalado que la relación de dichas personas con la Entidad en realidad es continua, que en la práctica obedecería a una de naturaleza laboral.

Al respecto, es necesario tener en cuenta que, para que se declare la existencia de una relación laboral, la vía correspondiente para su reconocimiento es la judicial, debiendo ser esta solicitada por la parte interesada; por lo cual, este Tribunal no puede determinar a partir de ciertos hechos determinar la existencia de un vínculo laboral cuando la autoridad competente no lo ha declarado.

Asimismo, este Tribunal no puede obviar que la orden de servicio recién fue emitida el 31 de enero de 2022, por lo cual no puede suponer o determinar que en los días anteriores en los que dichas personas no mantenían vínculo contractual tenían competencia para ejercer funciones como servidores o locadores de la Entidad.

20. Por otra parte, el Impugnante considera que el vicio encontrado debe conservarse, en tanto que no ha afectado el procedimiento de selección.

En el presente caso se ha vulnerado el artículo 44 del Reglamento, en tanto el comité de selección designado que efectuó actuaciones necesarias para el inicio del procedimiento de selección (elaboración de bases y convocatoria del procedimiento de selección), estuvo indebidamente conformado, al designarse a terceros sin ningún tipo de vínculo con la Entidad ni con alguna otra Entidad para formar parte del órgano colegiado que condujera el procedimiento.

En relación con ello, el artículo 44 de la Ley establece que el Tribunal o la Entidad, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdo marco.

Adicionalmente, los vicios advertidos significan no solo defectos u omisión de

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

alguno de sus requisitos de validez del acto administrativo (que conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG pueden ser materia de conservación), sino que, en el presente caso, además se trata de la contravención a normas reglamentarias, cuya causal de nulidad de pleno derecho, regulada por el numeral 1 del citado artículo no ha previsto dicha posibilidad de conservación (como tampoco lo ha hecho el artículo 14 del citado TUO de la LPAG, que faculta solo la conservación de vicios no trascendentes de incumplimiento a los elementos de validez del acto administrativo).

En el caso concreto, se evidencia que al designarse el comité de selección en contravención al artículo 44 del Reglamento, que contiene las reglas previstas para la conformación del comité de selección, no encontramos ante un órgano que no ha sido nominada regularmente, por lo que los actos que realizó (elaboración de bases y convocatoria) estaban afectadas por una causal de nulidad, estos es, por falta de competencia. Es pertinente tener en cuenta que las reglas allí previstas tienen especial relevancia, teniendo en cuenta que abordan las condiciones que debe cumplir el órgano colegiado que lleve a cabo el procedimiento de selección.

Visto así, considerando que la selección del proveedor tiene como finalidad que la Entidad seleccione a la persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la satisfacción de sus necesidades, es necesario que el comité de selección cuente también con las condiciones técnicas y legales correspondientes para ejercer sus funciones.

Precisamente, considerando que el miembro del comité se encuentre en algún régimen laboral o contractual del Estado, este reúne un marco normativo que contempla reglas para someter a procedimiento disciplinario a los funcionarios y/o servidores (o procedimiento administrativo sancionador para quienes estén vinculados contractualmente) que cometan ciertas irregularidades, en el marco del ejercicio de sus funciones. Además, en el caso de un contrato de locación de servicio, las Entidades deberán estipular dentro de los términos contractuales las penalidades o cláusulas necesarias ante incumplimientos que pudiera cometer el locador.

Ello, sin embargo, no es posible en el supuesto que el tercero que se designe no mantenga ningún tipo de relación con la entidad.

Esto explica por qué la designación de comité de selección vulnerando el artículo 44 del Reglamento configura un supuesto de nulidad de pleno derecho, porque nos encontramos frente a un órgano incompetente para realizar válidamente el procedimiento de selección.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

21. Por otro lado, el Impugnante ha manifestado que la resolución impugnada vulneraría el principio de predictibilidad y la seguridad jurídica; en tanto, que se ha declarado la nulidad del procedimiento por un supuesto vicio en la convocatoria cerca de un año después, lo cual, a su juicio, es irrazonable e inesperada para los proveedores, que habrían invertido tiempo y dinero en el procedimiento de selección y han llegado a coordinaciones y acuerdo con los fabricantes mundiales para cumplir sus obligaciones.

Al respecto, el principio de predictibilidad, recogido en el numeral 1.15 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, establece que la autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Asimismo, indica que las actuaciones de la autoridad administrativa deben ser congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. En ese sentido, el referido principio dicta que la autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente, no pudiendo actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

En ese escenario, la falta de predictibilidad se daría si habiendo un criterio fijado, la autoridad administrativa se aparte de él, sin motivar la razón de por qué lo hace, esto es, de manera arbitraria. En el presente caso, el Impugnante no ha señalado algún pronunciamiento en el que se repliquen las circunstancias que han ameritado la declaración de nulidad y en el que se haya resuelto de forma contraria; en tal sentido, no puede determinarse que ha existido algún apartamiento.

Por el contrario, la declaración de nulidad se ha sustentado en normas (artículo 44 de la Ley y numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG), al evidenciarse que existió un vicio del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho.

22. Adicionalmente, el Impugnante ha señalado que la entidad se ha comportado de manera contraria a la buena fe y a la doctrina de los actos propios, pues fue esta misma quien designó a los miembros del comité de selección, aprobó las bases y convocó el procedimiento de selección, por lo que no debería valerse de sus propios vicios para conseguir una nulidad sin sustento.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

El principio de buena fe procedimental, al que se remite el Impugnante, se encuentra recogido en el numeral 1.8 del artículo IV del título preliminar del TUO de la LPAG, según el cual la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe; y, en virtud del cual, la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la referida norma.

Precisamente, el principio establece como salvedad al hecho que la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, los supuestos de revisión de oficio contemplados en el TUO de la LPAG, que se encuentran recogidos en el capítulo I de su título III, siendo estos la rectificación de errores, la nulidad de oficio y la revocación.

- 23.** Como otro de los puntos de su recurso de apelación, el Impugnante advierte que existirían dos versiones del Informe Legal N° 400-OAL-CEABE-ESSALUD-2022, de fecha 20 de diciembre de 2022.

Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que la resolución materia de cuestionamiento, si bien se remite a dos informes (Informes N.º 1999-SGAYEC-GABE-CEABE-ESSALUD-2022 y N.º 400-OAL-CEABE-ESSALUD-2022) para detallar que la Sub Gerencia de Adquisiciones y Ejecución Contractual de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos y el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, respectivamente, estaban de acuerdo con declarar la nulidad del procedimiento, no es menos cierto que en la resolución se efectúa un análisis independiente de dichos informes, valorando los argumentos presentados por el Impugnante y otro de los postores; de allí que, inclusive su análisis se haya agotado en uno de los vicios y haya decidido obviar el de los otros dos puntos advertidos por dichas dependencias, por considerar que carecía de objeto, pues de igual manera se iba a retrotraer lo actuado a la etapa de convocatoria.

Sin perjuicio de lo expresado, este Tribunal considera conveniente trasladar lo señalado por el Impugnante a conocimiento de la Entidad.

- 24.** Por dicha razón, este Colegiado estima que la decisión adoptada por la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección por considerar que fue convocado por un comité de selección designado contraviniendo el artículo 44 del Reglamento es acorde a Ley.

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

25. Sin perjuicio del análisis realizado, este Colegiado considera que los hechos descritos en esta resolución deben ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional a fin de que adopten las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, en relación con el deslinde de las responsabilidades originadas, y que situaciones como las descritas no vuelvan a ocurrir. En el presente caso, se han destinado recursos de la Entidad para efectuar un largo procedimiento de selección cuya contratación no ha podido efectuarse, además de haberse esperado la adjudicación del ítem [y otros más] para determinar la nulidad del procedimiento de selección.
26. Por último, toda vez que el recurso se ha declarado infundado, en virtud del numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento, **debe ejecutarse la garantía presentada por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación.**

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Jorge Luis Herrera Guerra y la intervención de los vocales Héctor Marín Inga Huamán y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Declarar **INFUNDADO** el recurso de apelación interpuesto por la empresa Multimedical Supplies S.A.C., contra la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 143-PE-ESSALUD-2023 del 9 de febrero de 2023, que declaró la nulidad de la Licitación Pública N.º 003-2022-ESSALUD/CEABE – Primera Convocatoria (incluido el ítem N.º 33). En consecuencia, corresponde:
 - 1.1. **Confirmar** la nulidad de la Licitación Pública N.º 003-2022-ESSALUD/CEABE – Primera Convocatoria (incluido el ítem N.º 33), y retrotraerlo a la etapa de la convocatoria.
 - 1.2. **Ejecutar** la garantía otorgada por la empresa Multimedical Supplies S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

Tribunal de Contrataciones del Estado

Resolución N° 01626-2023-TCE-S3

2. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones, conforme a lo señalado en el fundamento 25.
3. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE HERRERA GUERRA
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE
VOCAL
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

HECTOR MARÍN INGA HUAMÁN
PRESIDENTE
DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE